

연차휴가제도의 보상적 성격에 관한 비판적 검토

김근주*

국문초록

흔히 「근로기준법」의 연차휴가제도를 보상적 성격의 휴가제도라고 표현하고 있다. 연차휴가는 비정기적 휴식제도로써 일정기간 동안 근로의무의 면제를 통해 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하고자 하는 취지에서 인정되는 것으로, 연차휴가에 관한 입법례를 살펴보면 일정한 근무기간이 경과한 후 고용 존속에 수반하여 부여되는 것이 보편적이다. 하지만 「근로기준법」상 연차휴가제도는 출근율을 기반으로 하는 요건을 충족해야만 부여되는 휴가이므로, 그 법적 성격을 설명하는데 있어서 ‘보상적 성격의 휴가제도’라는 표현보다 더 적절한 것은 없을 것이다.

그렇다면 국제기준 또는 다른 나라의 입법례와 달리 유독 우리나라에서만 연차휴가제도가 보상적으로 운용되는 이유는 무엇인지, 그 법적 타당성은 어디에 있는지가 명확하게 규명될 필요가 있다. 이러한 문제의식 하에서 이 글에서는 휴가제도의 전체적 구조, 연차휴가제도의 연혁, 휴가제도의 각 요건별 검토를 통하여 연차휴가제도의 보상적 성격의 타당성에 관한 검토를 수행하였다. 그리고 이러한 검토 과정에서 현행 연차휴가제도의 보상적 성격이 목적으로 하는 바가 명확하지 않으며, 고용 형태 등에 따라 차별적으로 규정되어 있다는 점을 확인하였다.

주제어: 연차휴가, 보상적 성격, 휴식제도, 주휴일, 비정규직 차별

* 金根住 : 한양대학교 강사(rockparty@hanyang.ac.kr)

— 목 차 —

- I. 글을 시작하며
- II. 휴식제도에서 휴가의 특성
- III. 휴가제도의 유형과 체계
- IV. 연차휴가제도의 변천 과정에 따른 보상적 성격의 변화
- V. 연차휴가의 구조에서 나타난 보상적 성격
- VI. 글을 마치며

I. 글을 시작하며

최근 대법원은 “쟁의행위 등에 있어서 연차휴가일 산정”과 관련하여, 연차 유급휴가(이하 연차휴가¹⁾)제도의 취지를 기왕의 근로제공에 대한 보상적 성격을 전제로 하여 연차휴가 취득 시 비례적 삭감설을 채택한 바 있다. 이 사건에서 결론에 관한 찬반 여부에 관해서는 여러 견해들이 제시되고 있는데²⁾, 이 글은 대법원의 결론에 주목하는 대신 대법원을 비롯한 법원과 학계에서 일반적으로 사용하는 연차휴가의 성격을 나타내는 표현인

-
- 1) 이 글은 연차휴가의 유급성에 관한 내용을 중점적으로 다루고 있지 않으므로, 연차 유급휴가를 연차휴가라고 약칭하도록 한다. 다만 연혁적 검토에서 법령의 제목 또는 조문의 인용시에는 ‘연차 유급휴가’라는 표현을 그대로 사용한다.
 - 2) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2011다4629판결에서는 연차휴가제도의 취지를 기왕의 근로제공에 대한 보상적 성격을 전제로, 정당한 쟁의행위에 참가한 기간과 육아휴직 기간 동안에는 원칙적으로 근로제공의무가 없으며 사용자 또한 근로의 대가를 지급할 의무도 없다는 점 등을 종합적으로 고려해 ‘연간 소정근로일수’에서 쟁의행위기간과 육아휴직기간 등이 차지하는 일수를 제외한 나머지 ‘실질 소정근로일수’를 기준으로 근로자의 출근율을 산정하도록 하였다. 이러한 판례의 태도에 대하여 기본적으로 찬동하는 견해(박종희, “연차휴가일수 비례산정의 타당성”, 『월간 노동법률』, (주)중앙경제, 2014. 03)와 반대하는 견해(노호창, “쟁의행위와 연차 유급휴가”, 『월간 노동리뷰』 중 노동판례리뷰, 한국노동연구원, 2014.03)가 제시되고 있다.

“보상적 성격”의 타당성에 관하여 검토해 보고자 한다.³⁾

대법원의 이번 판결(2011다4629)을 포함하여 기존 연차휴가에 관한 판례들에서는 그 법적 성격을 “보상적”이라고 표현하는 경우가 있다. 일정기간 동안 근로의무의 면제를 통해 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하고자 하는 연차휴가의 취지를 고려할 때⁴⁾, 현행 「근로기준법」상 연차휴가는 실질적인 휴식제도라고 하기 힘들다. 하지만 적어도 출근율을 바탕으로 연차휴가를 부여하고 있는 현행 「근로기준법」상 연차휴가제도를 설명하는 데 있어서 가장 적합한 표현은 ‘보상적 성격의 휴가제도’라는 점에는 큰 이의가 없는 듯하다.

그렇다면 연차휴가가제도가 ‘무엇을(보상의 대상)’, ‘어떻게(보상의 방식)’보상하기 위한 것인지를 검토하는 것은 연차휴가의 해석적 기준과 입법적 개선 방안을 마련하는 데 있어서 선행적으로 검토되어야 할 것이다. 특히 국제기준 또는 다른 나라의 입법례를 살펴볼 때 대다수의 근로자에게 보편적으로 인정되고 있는 연차휴가제도가 유독 우리나라에서 보상적으로 운용되고 있다는 점을 생각한다면, 그 보상의 대상과 방식은 법체제적으로 상당히 타당해야만 할 것이다.⁵⁾

3) 이 글은 필자의 학위논문(김근주, 『연차휴가제도에 관한 연구』, 한양대학교 박사학위논문, 2012)과 그에 대한 주요 요지를 요약한 글(김근주, “연차휴가의 입법적 개선 방안”, 『노동법학』 제50호, 2014)을 부분적으로 보완하기 위하여 작성한 것으로 일부 중복되는 부분이 있음을 밝혀 둔다.

4) 헌법재판소는 “연차 유급휴가는…근로자에 대하여 매년 일정 일수의 휴가를 유급으로 보장하는 제도로서, …근로자의 정신적·육체적 휴양을 통하여 문화적 생활을 향상을 기하려는 데 취지가 있다”라고 하면서 그 성격을 근로자에게 보장되는 ‘근로의 권리’로 본다(헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2005헌마586).

5) 이전 글들에서 필자는 연차휴가의 보장적 성격만을 강조하면서 입법적 지향점을 제시하는데 중점을 두었다. 단순한 당위로서의 보장적 성격을 강조하기보다는 왜 현행의 보상적 성격이 타당하지 않은지에 관하여 좀 더 검토하는 것이 필요하다고 생각했으며, 그에 보상적 성격이 법체계 내에서 용인 가능한 것인지에 관한 검토를 하고자 하였다. 이러한 관점에서 보면, 이 글은 연차휴가의 보상적 성격에 관하여 중립적으로 해석하고자 하기보다는 그 무용성과 불합리성을 지적하여 보장적 성격의 휴가가 되기 위하여 조속한 입법적 개정을 촉구하는, 일종의 비판적 검토라고 할 수 있다.

이러한 문제의식에 따라 이 글은 연차휴가의 체계와 관계 조문의 변천 과정에서 나타나는 특징들을 바탕으로 연차휴가제도의 보상적 성격의 대상과 방식, 그리고 그 타당성에 관하여 검토해 보도록 한다.

II. 휴식제도에서 휴가의 특성

1. 「근로기준법」상 휴식제도의 범위

「근로기준법」을 비롯한 노동관계법령에서는 ‘휴식’이라는 용어를 사용하고 있지만 법령에 따라 조금씩 상이한 내용을 규정하고 있으며, 그 명확한 범위에 관해서도 규정하고 있지 않다.

ILO 국제기준 및 EU 지침에서 휴식(rest periods)을 ‘근로시간이 아닌 모든 시간’이라고 정의하는 연장선상에서 생각해 보면⁶⁾, 「근로기준법」 제4장의 표제(근로시간과 휴식)에서 사용된 ‘휴식’이 제도로서의 휴식과 가장 유사하다고 할 수 있다. 즉 「근로기준법」상 휴식은 제4장 중 근로시간에 관한 규율 이외의 조문들, 즉 휴게(제54조), 휴일(제55조), 연차 유급휴가(제60조) 등을 포괄하는 상위의 개념으로 사용된 듯하다.

다만 「근로기준법」 제4장의 조문들 가운데에는 근로시간에 관한 것인지, 휴식에 관한 것인지 명확하게 구별하기 힘든 경우도 있다. 예컨대 제57조(보상 휴가제)의 경우 ‘휴가’에 관한 규정으로 휴식의 범주에 포함된다고 볼 수도 있지만, 보상휴가제의 본질이 연장·야간·휴일근로 가산임금에 대한 임금지급 특례이므로 근로시간에 관한 규정으로 볼 수도 있다.⁷⁾ 이

6) EU 근로시간의 편성에 관한 지침 제2조 제2항.

7) 이처럼 「근로기준법」 제4장 규정의 성격을 구별하는 것은 제63조(적용의 제외)의 범위를 확정하고자 하는데 실익이 있다. 「근로기준법」 제63조에서는 ‘근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정’에 대한 적용제외를 규정하고 있기 때문에, 근로시간에 관한 규정의 범위에 따라 적용제외 대상 조문이 정해지게 된다.

처럼「근로기준법」 제4장은 ‘근로시간에 관한 규율’과 ‘휴식에 관한 규율’을 명확하게 구별하기보다는 포괄적인 의미에서 ‘근로시간과 휴식’을 사용하고 있는 것으로 보인다.

2. 휴일의 해석과 연차휴가에 대한 적용 가능성

현행 「근로기준법」상 휴식제도는 제4장을 중심으로 휴게, 휴일, 연차휴가 등으로 구성되어 있으며, 이들은 비록 헌법상 명시적 위임은 없지만⁸⁾, 근로자의 ‘인간다운 삶’을 위한 전제조건으로 이를 보장하는 것은 「헌법」상 요청에 따른 것이다.

하지만 「근로기준법」의 해석을 살펴보면, 휴식제도의 부여와 적용에 있어서 동일한 수준의 보장을 하고 있지 않은데, 특히 정기적 휴식제도인 휴게·휴가의 부여와 비정기적 휴식제도인 연차휴가 및 기타 휴가·휴식의 부여에서 큰 차이가 나타나고 있으며, 이를 단적으로 나타내 주는 사례가 주 휴일의 부여와 연차휴가의 부여에서 유급성을 둘러싼 해석이다.

「근로기준법」 제55조는 “사용자는 근로자에게 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 주어야 한다.”고 규정하고 있으며, 「근로기준법」시행령 제30조는 “법 제55조에 따른 유급휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 자에게 주어야 한다.”고 규정하고 있다. 따라서 일반적으로 「근로기준법」시행령 제30조의 개근을 요건으로 하여 근로기준법 제55조의 유급휴일을 부여해야 한다고 설명되고 있다. 이 때 유급휴일을 부여한다는 의미는 휴일에 근로를 제공하지 않더라도 휴일임금을 지급함과 동시에 24시간 이상의 휴식을 보장하여야 한다는 것을 의미한다.

그렇다면 「근로기준법」시행령 제30조에서 정한 요건(1주간 소정근로일의 개근)을 미달하는 경우의 효과는 어떻게 해석하여야 할 것인가? 이에 관해

8) 일본 헌법 제27조 제2항은 “임금, 취업 시간, 휴식 기타의 근로조건에 관한 기준은 법률로 이를 정한다”라고 규정하여 근로조건 법정주의의 예시로 근로(취업)시간과 휴식제도를 구분하여 들고 있다.

서는 견해는 휴가 부여 부정설과⁹⁾ 무급휴가 부여설로 나뉠 수 있는데, 판례 및 행정해석은 무급휴가 부여설의 입장에 있다.¹⁰⁾

휴일은 정기적인 휴식제도로써 일정 시간의 지속적 휴식을 통하여 근로자에게 생애적 회복과 시민으로서의 삶을 누릴 수 있는 비-구속시간을 보장하는 것을 그 내용으로 한다. 「근로기준법」 제55조 역시 사용자가 근로계약 체결 시 반드시 주휴일을 배치하도록 하여 그 정기적 성격을 중시하고 있는데, 이에 따르면 주휴일은 원래부터 근로제공의무가 없이 소정근로일에서 제외되게 되며, 결국 사용자는 근로계약 단계에서 주휴일을 반드시 부여할 수밖에 없게 된다. 이처럼 휴식제도로써의 휴일이라는 취지를 고려한다면 무급휴가 부여설이 타당하다고 생각된다. 무급휴가설의 타당성은 법체제적인 측면에서도 그 정당성을 찾을 수 있다. 즉 휴가에 관하여 법률에서 정한 의무를 이행하는 내에서 시행령에서 규정한 요건을 유급 요건으로 해석하는 것이 더 체계적이라고 할 수 있기 때문이다.

결론적으로 휴일에 관한 해석에 있어서 1주간의 소정근로일에 개근을 하면 유급휴일이 부여되는데, 여기서 개근은 ‘휴일’의 요건이 아니고 ‘유급’의 요건이 된다. 1주간의 소정근로일을 개근하면 휴일임금이 지급되고, 하루라도 결근을 하면 휴일임금이 지급되지 않는다.

그렇다면 연차휴가 역시 취득 요건에 있어서 출근율 요건을 유급휴가의 요건으로 국한되어 해석하는 것이 가능할까? 출근율 요건을 충족하는 범위에서는 유급휴가를 부여하고, 그렇지 못한 한도에서 무급휴가를 부여하는 것이 가능할까?

그러나 휴식제도로써의 연차휴가를 강조함으로써 출근율 요건은 단지 유급 요건에 국한된다고 해석하기에는 「근로기준법」상 연차휴가는 취득과

9) 휴가 부여 부정설에 따르면 소정근로일에 결근한 근로자는 주휴일에 출근해야 하며, 출근하지 않으면 결근이 된다는 논리가 성립한다. 이에 반하여 무급휴가 부여설에 따르면 법정 요건을 충족하지 않는 경우 주휴일을 부여하여야 하지만 이를 무급으로 처리해야 한다고 본다(하갑래, 『근로기준법(제26판)』, (주)중앙경제, 2015, 351면).

10) 대법원 2004. 6. 25 선고 2002두 2857판결 ; 근기 01254-9370.

사용에 있어서 상당히 기술적이고 복잡한 보상적 기준들을 규정하고 있다. 이러한 입법태도는 본질적으로 휴가 및 휴직 등 비정기적 휴식제도들이 취득과 사용의 이단계로 구분되어 있다는 전제에 따른 것인데, 그러므로 휴가에 관해서는 취득과 사용에서 발생하는 수많은 법률적 문제들이 제기될 수 있으며, 이는 휴식제도로서의 연차휴가의 성격만으로 해결될 수 없다.

III. 휴가제도의 유형과 체계

1. 휴가제도 유형화의 필요성

근로자의 ‘휴가’를 규정하고 있는 법령의 총체를 휴가제도라고 보면, 이들은 「근로기준법」을 중심으로 노동관계법령에 산재되어 위치하고 있다.¹¹⁾ 「근로기준법」은 연차휴가를 중심으로 한 다양한 휴가제도들과 함께 휴일 및 휴게 등 휴식제도에 관한 기본법의 역할을 하고 있다.

현행 노동관계법령상 휴가들은 다양한 입법 목적을 가지고 도입되었기 때문에 단일한 분류 기준에 따른 유형화가 어렵다. 하지만 각각의 휴가제도들을 비교할 때 나타나는 특성들을 기준으로 휴가제도를 유형화한다면 개별 휴가제도의 법적 성격을 보다 명확하게 할 수 있을 것이다. 그리고 이를 통하여 어떤 휴가제도의 해석적 공백이 발생할 때 유추해석의 범위

11) 이하에서는 노동법을 규율하고 있는 성문법령들을 노동관계법령으로 지칭하도록 한다. 노동법 및 노동관계법령의 정확한 범위는 논자(論者)에 따라 차이가 있지만, 여기에서는 「근로기준법」과 이에 대한 특별법적 성격이 있는 「선원법」등의 근로조건 규율 법령을 비롯하여, 「노동조합 및 노동관계조정법」과 같은 집단적 노사관계 관련 법령들, 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」과 같은 노사협력 관련 법령들, 「고용보험법」, 「산업재해보상보험법」, 「산업안전보건법」등의 고용·산재보험 관련 법령들과 기타 법령들에서의 근로조건 관련 규정을 포괄하는 개념으로 사용하도록 한다.

를 확정하거나¹²⁾, 새로운 휴가제도 도입이나 기존의 휴가제도들의 개선 방안을 체계적으로 접근할 수 있도록 하는 지침으로서 작용할 수 있다. 이하에서는 휴가의 법적 근거, 휴가의 유급성 여부, 휴가의 법적 성격 등을 바탕으로 노동관계법령상 휴가를 유형화하고자 한다.

2. 휴가의 구별 기준

(1) 법적 근거에 따른 구분

휴가를 법적 근거 유무에 따라 구별한다면 법정휴가와 약정휴가로 나눌 수 있다.

양 당사자 사이의 계약은 그 의사표시에 하자가 없는 한, 당사자의 자유로운 의사에 따라 정하는 것이 원칙이다. 그러나 「헌법」 제32조 제3항은 “근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다”라고 하면서, ‘적정임금의 보장에 노력’ 및 ‘최저임금제 실시’(제32조 제1항), ‘여성과 연소자의 근로에 대한 특별한 보호’(제32조 제4항 및 제5항), ‘여성의 근로조건에 관한 부당한 차별 방지’(제32조 제4항) 등 근로조건에 관한 보호를 규정하고 있다.

경제적 관점에서 볼 때 사용자에게 근로자는 생산의 한 요소이므로 그 효율적 이용이 중시되며, 이러한 경향은 산업화 과정이 진행됨에 따라 더욱 심화되고 있다. 이에 사용자와 근로자의 근로계약 체결과 그 이행 과정에서 경제적 목적을 이유로 한 근로자의 ‘인간의 존엄성’ 침해가 당연히 예상되는 바, 「헌법」은 이를 방지하기 위하여 근로조건이 ‘인간의 존엄성’을 침해하지 않도록 보호할 국가의 의무에 근거하여 근로조건에 관한 최저기준을 법령으로 설정하도록 하고 있다. 헌법상 보호하고자 하는 ‘근로조건’은 임금 및 그 지불방법, 근로시간과 휴식시간, 안전·위생시설, 재해

12) 유추해석은 법의 탄력적 운용을 그 기본 전제로 하여 입법상의 공백을 메우기 위한 해석 방법론의 하나이지만, 그 유추해석의 한계가 명확하지 않을 경우 유사성에 대한 판단이 자의적으로 이루어질 수 있으므로 법적 안정성을 침해하게 된다.

보상 등 근로계약상 권리·의무들과 관련된 모든 조건들을 말한다. 노동관계법령에서 규정하는 휴가 역시 헌법에 근거한 법정 근로조건이다(법정휴가).

이에 반해 약정휴가는 사적자치의 원칙에 근거를 둔 ‘근로조건 자율결정의 원칙’에 따라 당사자 사이의 합의에 의하여 근로조건으로 편입된 것으로, 단체협약 및 취업규칙, 그리고 근로계약에 따라 근로조건으로 확정된 휴가를 말한다. 약정휴가는 법정휴가와 달리 그 내용에 관하여 법령상 특별한 제한은 없지만, 일단 근로조건으로 편입된 이상 근로조건 명시 의무¹³⁾ 법적 의무가 적용됨은 물론 당사자의 권리·의무에 관한 법원(法源)이 된다.

법정휴가와 약정휴가는 그 명칭에 따라 구분되는 것은 아니므로, 예컨대 취업규칙상 연차휴가를 다른 명칭으로 규정하였다고 해서 약정휴가가 되는 것은 아니다.¹⁴⁾ 그리고 일반적으로 ‘법정(法定)’에서 ‘법(法)’이란 입법기관이 ‘법률’의 형식으로 제정하는 형식적 의미의 법뿐만 아니라 법률에 따른 위임입법인 시행령과 시행규칙 등을 포괄하는 의미로 사용된다.¹⁵⁾ 그러나 사적(私的) 관계인 근로계약관계에 관한 법원(法源)이 되는 시행령과 시행규칙 등은 법률의 위임에 따라 국민의 권리와 의무를 직접 규율하는 법규

13) 「근로기준법」 제17조 제4호는 ‘제60조에 따른 연차 유급휴가’만을 명시하여야 할 근로조건으로 규정하고 있다. 그러나 동조 제5호의 ‘그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건’에 관하여 「근로기준법 시행령」 제8조는 제2호에서 ‘법 제93조 제1호부터 제12호(취업규칙의 작성·신고 사항)’에서 정한 사항에 대한 명시 의무를 규정하고 있다. 「근로기준법」 제93조 제1호에서는 ‘업무의 시작과 종료 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대근로에 관한 사항’을 규정하고 있으므로, 연차휴가뿐만 아니라 일반적인 휴가에 관한 사항도 근로계약상 명시하여야 할 근로조건이 된다.

14) 1990년대 후반부터 일부 대기업을 중심으로 시작되었던 리프레시(refresh)휴가의 내용을 살펴보면, 단순히 연차휴가를 리프레시 휴가로 명명하거나, 설이나 추석 연휴의 앞뒤에 연차휴가를 묶어서 재배치하는 유형이 주(主)를 이루고 있는데(김영선, 『잃어버린 10일-경영 담론으로 본 한국의 휴가 정치』, 이학사, 2011, 278면), 이러한 휴가의 기본적인 내용이 연차휴가를 바탕으로 하고 있다면, 「근로기준법」상 규율을 받게 된다.

15) 권영성, 『헌법학원론』, 2011 법문사, 682면.

명령에 한정되므로¹⁶⁾, 행정 내부의 조직과 활동을 규율하는 고시·훈령·예규·통첩 등의 행정명령들은 대외적 구속력이 인정되지 않는다. 따라서 「국가공무원복무규정」 제3장에서 정한 휴가와¹⁷⁾ 교육과학기술부 예규에 따른 휴가 등은 그 형식상 법령이라는 방식에 의하여 규정되고 있지만, 이는 법규명령이 아닌 행정명령으로 그 법적 성질은 취업규칙과 유사하다. 그러므로 공무원 등에 적용되는 행정명령에 규정된 휴가들은 신분의 특수성에 따라 적용되는 약정휴가로 보고 그 정당성을 판단해야 한다.¹⁸⁾

(2) 휴가의 유급성에 따른 구분

휴가 기간 동안의 사용자의 임금지급 유무에 따라 휴가를 구분하면, 유급휴가와 무급휴가로 나눌 수 있다. 법정휴가 중 「근로기준법」 제57조(보상휴가), 제60조(연차 유급휴가) 등은 유급으로 규정되어 있으며, 「근로기준법」 제73조(생리휴가), 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의2(배우자 출산휴가) 등은 무급으로 규정되어 있다.

휴가의 유급성은 ‘사용자에 의한 임금지급 유무’에 따라 판단되는 것이므로, 사용자가 아닌 제3자에 의하여 금전이 지급되는 경우라 하더라도 무급휴가가 된다. 따라서 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 산전후 휴가급여가 지급되는 우선지원 대상기업 근로자의 출산전후휴가는 「고용보험법」 제19조 제2항에 따라 고용보험에서 90일분

16) 「헌법」 제32조 제3항은 ‘근로조건을 법률로 정하도록’ 하고 있고, 이러한 법률에 근거한 법규명령과는 달리 행정규칙은 헌법과 법률에 근거를 요하지 아니하고 그 고유의 권한에 따라 실시된다(이에 관해서는 노동법실무연구회(김홍준 집필부분), 『근로기준법주해 I』, 박영사, 2010, 24-25면 참조).

17) 「국가공무원복무규정」 제14조에서는 공무원의 휴가를 연가(年假), 병가, 공가(公假) 및 특별휴가로 구분하고 있으며, 이는 공무원 신분 일반에 적용된다. 이 외에도 각 공무원의 근로조건에 관한 행정규칙에서는 그 특성에 맞는 별도의 휴가가 규정되어 있다(「경찰공무원복무규정」 제18조 및 「소방공무원복무규정」 제9조의 포상휴가, 「군인복무규율」 제39조의4 청원휴가와 제39조의5 특별휴가 등).

18) 행정규칙을 약정 근로조건으로 파악하는 입장의 근거에 대해서는 노동법실무연구회(김홍준 집필부분), 위의 책, 25면 참조.

전체에 대한 산전후 휴가급여가 지급되므로 무급휴가이다. 출산전후휴가는 최초 60일은 유급휴가이지만, 나머지 30일은 무급휴가로 규정되어 있다(「근로기준법」 제74조 제4항).

휴가의 유급성은 개별 휴가의 취지를 고려하여 결정된다. 휴가의 취지에 따라 사용자가 근로자의 소득 보전을 책임져야 하는 경우도 있고, 근로자가 휴식을 받는 대신 임금 소득을 포기해야 하는 경우도 있다.¹⁹⁾ 또한 사용자가 소득 보전을 책임지지 않고 제3자가 소득 보전을 하는 경우도 있다. 예컨대 출산전후휴가의 경우 임신 및 출산 기간 동안의 근로자의 소득 보전 필요성이 강하게 요청된다. 그러나 이러한 때의 소득 보전은 사용자가 전적으로 책임질 성질의 것이 아니라 국가(사회보험)의 보호의무의 범위에 있는 영역이라 할 수 있다. 따라서 우선지원 대상기업에서는 국가가 근로자의 소득보전 책임을 전적으로 부담하고(무급휴가), 우선지원 대상기업이 아닌 경우에는 국가와 사용자가 근로자의 소득보전 책임을 공동으로 부담한다.

휴가의 유급성은 개별 휴가의 해석에 있어서 휴가기간 동안의 권리·의무 관계를 해석하는 기준이 되기도 한다. 예컨대 동일한 취지와 내용의 휴가를 유급으로 보장하는 경우와 무급으로 보장하는 경우를 비교하면, 전자에서 사용자는 주된 의무(임금지급)를 이행하는 대신 근로자에게 부수적 의무의 이행을 후자에서보다 더 강하게 요구할 수 있다. 따라서 휴가는 원칙적으로 근로자에 의해 자유롭게 이용되어야 하지만, 유급휴가의 경우에는 무급휴가보다 부수적 의무의 이행에 따른 일정한 행위의 제한이 가능하다.²⁰⁾

19) 유급휴가는 근로자의 근로제공 의무가 면제되지만 사용자의 임금지급 의무가 존속함에 반해, 무급휴가는 근로자의 근로제공 의무의 면제에 따라 이에 상응하는 사용자의 임금지급 의무도 없게 된다. 유급휴가가 소득이 보전되면서 휴식을 취할 수 있기 때문에 근로자의 휴가를 실질적으로 보장하는 방식이 될 수 있겠지만, 임금 수준의 저하 없이 유급휴가가 무급휴가로 전환된다면 시간급의 상승효과가 있으므로, 무급휴가가 반드시 근로자에게 불이익한 것으로 볼 수는 없다.

20) B. Alan, *Paid Annual Leave and the Long Term Sick: Third Time Lucky for the United Kingdom*, *Industrial Law Journal* 36(3), 2007, p.347.

(3) 휴가의 법적 성격에 따른 구분

노동관계법령상 휴가를 법적 성격, 특히 취득 요건을 중심으로 구분해 본다면 보상적 휴가와 보장적 휴가로 나눌 수 있다. 법적 성격에 따른 휴가의 구분은 법적 근거(법정휴가와 약정휴가), 유급성(유급휴가와 무급휴가)과 같이 명확한 것은 아니다. 그러나 이러한 방식에 따라 휴가를 구분하는 것은 ‘보편적인 최소 휴식’인 연차휴가를 출근율을 통해 판단하는 「근로기준법」의 특성을 반영할 수 있는 방식이다.

보상적 휴가는 ‘근로자의 기여도’에 따라 휴가의 취득 및 휴가일수에 차이가 있는 휴가이며, 보장적 휴가는 일정한 사실에 대하여 부여되는 휴가이다. 「근로기준법」 제74조는 보장적 성격을 명확하게 하기 위하여 ‘보호휴가’라는 표현을 사용하기도 하였다.²¹⁾ 휴식제도의 일환으로 휴가를 파악한다면 휴가는 근로자의 휴식을 위한 것으로 ‘보편적인 최소 휴식’은 ‘근로자의 기여도’를 불문하고 부여되어야 하지만, 「근로기준법」상 연차휴가는 출근 요건에 따라 휴가 취득이 결정될 뿐만 아니라(근로보상적 휴가²²⁾) 계속 근로기간에 따라 차등적으로 부여되는 휴가이다(공로보상적 휴가²³⁾). 연차휴가 외에도 「근로기준법」 제57조에 규정된 보상휴가 역시 근로자가 축적한 연장·야간·휴일근로에 비례하여 휴가의 취득 및 휴가일이 결정되

21) 2012년 개정 「근로기준법」[시행 2012.8.2.][법률 제11270호, 2012.2.1., 일부개정]은 제74조의 법문에 ‘보호휴가’라는 용어를 단순히 ‘휴가’로 변경하였는데, 그 이유에 관해서는 동법의 【제·개정문】 및 국회속기록 등 입법자료에서는 명시적으로 밝히고 있지 않다. 다만 【제·개정문】에 나와있듯이, ‘산전과 산후’를 ‘출산 전과 출산 후로’ 변경하는 등 문구를 수정한다고 하는 표현을 사용한 것을 보면, ‘보호휴가’를 ‘출산전후휴가’로 변경한 것 역시 단순한 문구 수정으로 생각한 듯하다. 그러나 출산전후휴가의 보장적 성격을 명확하게 하기 위한 보호휴가라는 문구를 삭제하고 단순히 ‘휴가’라고 하는 것은 법적 성격이라는 측면에서 볼 때 타당하다고 할 수 없다.

22) 하갑래, 앞의 책, 389면.

23) 하갑래, 위의 책, 353면에서는 연차휴가를 1년의 근로에 대한 근로보상적 성격과 함께 계속 근로에 따른 성과임금의 후불지급이라는 성격을 갖는 공로보상적 성격이 같이 공존하고 있다고 설명하고 있다.

므로 보상적 성격의 휴가이다. 연차휴가 취득 요건은 ‘대상 기간의 근로’에 대한 보상적 성격을 중심하기 때문에 이를 바탕으로 근로보상적 휴가라고 한다면, 보상휴가는 연장·야간·휴일근로로 침해받은 휴식에 비례하여 휴가가 부여되므로 휴식보상적 휴가라고 할 수 있다.

이에 반해 「근로기준법」상 생리휴가(제73조)나 출산전후휴가(제74조)와 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」상 배우자 출산휴가(제18조의2)는 보장적 성격의 휴가이다. 보장적 휴가는 근로자의 고용형태나 계속 근로기간 등에 관계없이 생리, 임신과 출산(유산과 사산 포함), 배우자의 출산 등의 법적 사실에 의하여 부여되는 휴가이다. 「고용보험법」 제75조에서는 출산전후휴가 급여를 지급하기 위한 요건으로 ① 휴가가 끝난 날 이전에 피보험 단위기간이 통산하여 180일 이상일 것 ② 휴가를 시작한 날 이후 1개월부터 휴가가 끝난 날 이후 12개월 이내에 신청할 것을 규정하고 있지만, 이는 출산전후휴가 급여의 지급 요건일 뿐 출산전후휴가의 부여 요건은 아니다.

3. 휴가제도의 체계

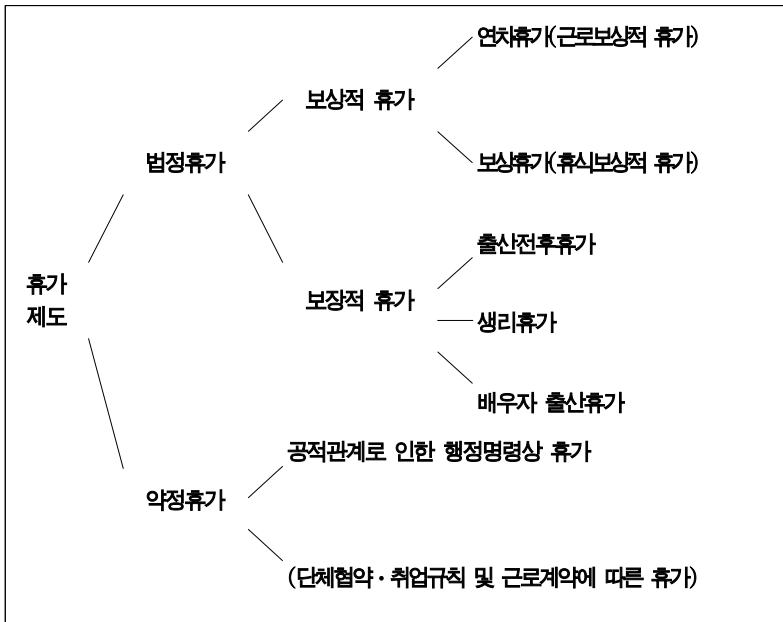
(1) 휴가 유형에 따른 휴가제도 체계

휴가제도는 각기 다른 휴가들의 총체(總體)이므로, 단일한 기준에 따라 의미 있는 체계화를 도출하기에는 무리가 있다. 그러므로 휴가의 유형화는 일정한 목적에 따라 분류 기준을 종합적으로 고려할 필요가 있다.

<표 1>에서는 휴가제도를 법적 근거에 따라 법정휴가와 약정휴가로 구분한 후, 법정 휴가를 법적 성격에 따라 보상적 휴가와 보장적 휴가로, 약정휴가를 법적 근거에 따라 행정명령상 휴가와 단체협약·취업규칙 등에 따른 휴가로 구분하였다.²⁴⁾

24) <표-1>의 휴가제도의 체계는 노동관계법령과 노동현실에서 나타나고 있는 모든 휴가들을 포섭하기 목적으로 각 구분 기준들을 활용한 것이다.

<표 1> 휴가제도의 체계



(2) 보상적 휴가와 보장적 휴가 구별의 의의

다른 나라의 입법례를 살펴보면, 부성휴가나 입양휴가와 같은 돌봄노동을 위한 휴가나 유급병가 등을 규정하고 있는 경우도 있지만²⁵⁾, 아직까지 다양한 목적에 따른 법정휴가가 활성화되지 않은 현행 노동관계법령에서는 비교적 단순한 법정휴가를 규정하고 있다.²⁶⁾

<표 1>에서 열거된 휴가 중 배우자 출산휴가를 제외한 법정휴가는 모두

25) 장지연, “출산 및 양육과 관련된 휴가제도의 국제비교”, 『국제노동브리프』 2005년 3월호, 한국노동연구원, 33-42면 참조.

26) 1953년 「근로기준법」 제정 과정에서 적치와 분할 사용이 가능한 ‘1개월에 대하여 2일의 유급병가’의 도입이 논의되었지만, 경제적인 상황 등을 고려하여 결국 입법화되지 못하였다. 이에 관한 자세한 논의는 이흥재, 『노동법 제정과 전진환의 역할-국회속기록의 현장증언-』, 서울대학교출판문화원, 2010, 183-184면 참조.

「근로기준법」에 규정되어 있다. 해석상 공백이 발생할 경우 동일 법령에 있는 동일 개념이 최우선적 고려 대상이라는 점을 고려할 때, 「근로기준법」상 휴가 규정들은 상호 영향 속에서 해석되는 것이 타당하다. 그럼에도 불구하고 보상적 휴가와 보장적 휴가는 그 목적부터 내용까지 차이가 있는데, 양 자의 차이를 비교해 보면 다음과 같다.

먼저 휴가의 목적에 관하여, 보장적 휴가는 특정한 입법적 목적을 위해 규정된 휴가인 반면, 보상적 휴가는 그 목적에 제한을 받지 않는다. 현행 노동관계법령의 보장적 휴가는 주로 모성보호를 위한 목적으로 규정되어 있는데, 근로자가 보장적 휴가를 부여받기 위해서는 ‘법적 요건 사실의 발생’을 사용자에게 증명하여야 한다.²⁷⁾ 이에 반해 보상적 휴가는 근로자의 기여도에 따라 휴가를 취득한 후 행사하는 휴가로서 특정한 목적에 제한을 받지 않는 휴가이다.²⁸⁾

다음으로 휴가의 시기지정 및 휴가권의 성격에 관하여, 보상적 휴가는 근로자에게 휴가시기의 주도권이 있음에 반해(청구권적 성격), 보장적 휴가는 확정권이 있다고 할 수 있다(형성권적 성격). 연차휴가는 근로자가 원칙적으로 시기지정권을 행사하지만 이에 대응한 사용자의 시기변경권이 규정되어 있으며, 보상휴가는 별도의 휴가 시기지정 원칙을 규정하지 않고 있다. 이에 반해 보장적 휴가인 생리휴가나 출산전후휴가, 그리고 배우자 출산휴가 등은 근로자의 휴가시기 지정에 대응하는 사용자의 권한이 없다.

마지막으로 휴가미사용과 금전보상에 관하여, 보장적 휴가는 휴가미사용에 대한 금전보상이 인정되지 않는 휴가임에 반하여, 보상적 휴가는 금전보상이 원칙적으로 인정되는 휴가이다. 연차휴가나 보상휴가는 ‘근로자의

27) 다만 출산전후휴가와 배우자출산휴가에서의 출산이라는 사실이 외형 또는 의료기록 등에 의하여 쉽게 증명됨에 반하여, 생리휴가에서의 ‘생리 유무’의 증명은 근로자의 프라이버시와 연계되어 있으므로 증명 책임을 근로자에게 부담하도록 하는 것이 타당한지에 관해서 견해의 대립이 있다.

28) ILO 제132호 「연차 유급휴가협약(수정)」 제13조에서는 “각국의 권한 있는 기관이나 적당한 기관은 근로자가 휴가기간 중 휴가의 목적에 합치되지 아니하는 유사 활동에 종사하는 경우에 대해서 특별한 규칙을 정할 수 있다”라고 규정하여 연차 휴가의 목적상의 제한을 유사활동에 국한하고 있다.

기여도'에 따라 부여받는 휴가이기 때문에, 휴가의 행사 기간 내 휴가일을 사용하지 못한 경우에는 금전보상이 문제가 된다. 특히 보상휴가의 경우에는 축적되는 휴가일의 본질은 연장·야간·휴일근로의 가산임금이므로 휴가일의 미사용에 대하여 반드시 금전보상이 이루어져야 한다. 이에 반해 보장적 휴가는 '법적 요건 사실의 발생'에 따라 '특정한 날 또는 기간'에 부여되어야 하는 휴가로서 이러한 날 또는 기간이 도과하면 휴가권은 소멸하며, 그 미사용에 따른 금전보상이 문제되지 않는다. 이상의 점을 바탕으로, 보상적 휴가와 보장적 휴가의 차이점을 도식화하면 다음과 같다.

<표 2> 보상적 휴가와 보장적 휴가의 비교

구 분	보상적 휴가	보장적 휴가
휴가 목적	목적 개방적 휴가	목적 제한적 휴가 : 모성보호 등
편제	「근로기준법」 제4장	「근로기준법」 제5장 등 ²⁹⁾
시가지정	보상휴가 : 명확하지 않음 연차휴가 : 근로자의 청구(원칙)	근로자에 의한 확정
휴가미사용과 금전보상	금전보상 인정(원칙)	금전보상 인정되지 않음
휴가일수	차등적 부여	통일적 부여
휴가 취득	보상휴가 : 연장근로 등 연차휴가 : 출근요건 충족	법정 요건 사실의 발생
제제	보상휴가 : 없음 연차휴가 : 별칙규정	생리휴가/출산전후휴가: 별칙규정 배우자출산휴가: 과태료 ³⁰⁾

29) 배우자 출산휴가는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제3장 모성보호에 편제되어 있다.

30) 「근로기준법」상 휴가제도의 위반에 대하여 형사처벌이 규정되어 있는 것과 달리, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」상 배우자 출산휴가 위반은 행정벌(500만원 이하의 과태료)이 규정되어 있다(제39조 제2항 제3호).

IV. 연차휴가제도의 변천 과정에 따른 보상적 성격의 변화

1. 연차휴가제도의 도입

(1) 제정 「근로기준법」상 규정과 해석

1953년 제정 「근로기준법」은 제48조(연차 유급휴가)에서 ① 1년간 개근한 근로자에 대하여는 8일, 9월 이상 출근한 자에 대하여는 3일의 휴가 부여(제1항) ② 1년간 유급휴일의 총일수가 20일 이상이 되는 경우에는 그 초과분에 대하여 가산임금을 지급하고 휴가 부여의무 면제(제2항)³¹⁾ ③ 근로자의 시기청구권과 사용자의 시기변경권(제3항)³²⁾ ④ 휴가 기간 임금을 평균 임금으로 지급(제3항) ⑤ 근로자의 업무상 부상 또는 질병으로 휴업한 기간과 산전후 휴업 기간의 출근 간주(제4항)를 규정하였다.

1953년 제정 「근로기준법」은 연차휴가 외에도 1월당 1일의 월차휴가(제47조), 생리휴가(제59조)를 유급으로 규정하고 산전후를 통한 60일의 유급 보호휴가(제60조)도 규정하였다. 이러한 휴가제도의 기본적인 틀은 2003년 개정 「근로기준법」에 의하여 월차휴가가 폐지되고 보상휴가가 도입되기 전까지 50여 년간 유지되어 왔다. 또한 1953년 「근로기준법」의 제정 논의에서는 매월 2일의 병가를 유급으로 부여하는 방안도 제출되는 등 입법 과정에서 다양한 휴가제도들이 논의되었다.³³⁾

1953년 제정 「근로기준법」에서는 ‘유급휴일’의 총일수는 20일로, 20일을 초과하는 경우 그 초과분에 대해서는 통상임금의 100분의 50이상을 가산

31) 1953년 제정 「근로기준법」상 가산임금의 기준은 제46조(시간외휴일근로)에서 통상임금의 100분의 50이상으로 규정하였다.

32) 사용자의 시기변경권과 관련하여 1953년 「근로기준법」 제정 당시 국회에서는 사업에 지장이 없는데도 불구하고 일을 강행시키는 악질적인 사용자 때문에 이를 예방하기 위하여 ‘노동위원회의 동의’를 요구하는 수정안이 제기되기도 하였다(이흥재, “근로기준법 제정심의회 주요쟁점”, 「서울대학교 법학」, 제50권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2009, 102면).

33) 이흥재, 앞의 논문, 107-108면 참조.

한 임금을 지급할 수 있도록 하는 ‘휴가 금전보상’을 규정하였다(제48조 제2항 ; 제46조) 이 때 ‘유급휴일’은 주휴일 등이 아닌, 유급으로 보장된 휴가일(월차휴가일, 연차휴가일)을 의미하였다.³⁴⁾

(2) 제정 「근로기준법」상 연차휴가의 보상적 성격

1953년 제정 「근로기준법」상 연차휴가 규정을 살펴보면, ① 연차휴가 취득 요건에서 출근율을 설정하고, ② 연·월차휴가의 상한(20일)을 규정함과 동시에, ③ 상한 초과분에 관해서는 50% 이상의 가산임금을 부과하는 엄격한 금전 보상이 이루어지는 구조를 취하고 있었다. 현행 연차휴가 규정과 비교하면, 출근율과 상한 설정은 동일하지만 금전 보상의 엄격성이 특징적으로 나타나고 있으므로 보상적 성격이 좀 더 강하다고 평가할 수 있다.

연차휴가제도의 설계 당시, 어떠한 목적과 이유로 이러한 보상적 성격의 휴가제도가 도입되었는지는 명확하지 않다. 다만 당시 ILO의 제52호 「연차 유급휴가 협약」(1936)을 살펴보면, ‘1년 이상 계속 근로한 근로자에게 6일의 유급휴가일(paid holidays)을 부과하도록 하였으며(제2조 제1항)³⁵⁾, 이 협약에서 정한 계속 근로기간(1년)을 넘는 요건을 설정하는 등 휴가일 부여에 대하여 별도의 요건을 부여하는 것을 인정하고 있었다(제2조 제4항). 이러한 규정 방식은 우리나라의 입법에 직·간접적 영향을 미쳤던 일본 등 다른 국가에서도 나타나는 형태로³⁶⁾, 당시 연차휴가의 보상적 성격

34) 생리휴가와 출산전후휴가는 「근로기준법」 제5장에 규정된 보호휴가로 ‘휴가 금전보상’의 적용 대상이 되지 않았다(신인령, 『여성·노동·법』, 풀빛, 1985, 89면).

35) 현재 연차휴가를 표현하는 용어인 “Annual Leave”와 “Annual Holidays”는 현재에는 동일한 의미로 사용되지만, 연혁적으로 볼 때 전자가 휴가 일괄 사용 원칙을 바탕으로 하는 반면, 후자는 유급 휴일의 집합체로 보았다는 점에 차이가 있다. 이에 관해서는 European Industrial Relations Observatory, *Guidance on the implementation of the European Working Time Directive*, 2005 50-51면 참조.

36) 일본 제정 노동기준법은 ‘8할 이상 출근한 자에 대해 6일의 유급 휴가를 부여함과 동시에 2년 이상 계속 근무한 근로자에 대한 가산휴가’를 규정하였다. 이후 1987년 법개정에 의해 ‘6개월간 계속 근무하고 전체 근로일의 8할 이상 출근’(제

은 보편적인 입법 방식이라고 할 수 있다.

1953년 제정 「근로기준법」상 휴가제도에서 특징적인 점은 월차유급휴가인데, 별도의 출근 요건 없이 1월에 대하여 1일의 유급휴가를 부여함과 동시에(제47조 제1항), 근로자의 자유의사로 적치 또는 분할하여 사용할 수 있도록 하였다(제47조 제2항). 월차휴가는 출근을 등 그 취득에 대하여 특별한 요건이 규정되어 있지 않은 ‘보장적 성격’의 휴가로서, 근로자의 의사에 따른 적치·분할이 가능하다는 점 외에는 사실상 (월 단위) 휴일과 같은 역할을 담당하였다. 월차휴가의 입법 배경은 분명하지 않지만 「근로기준법」의 제정 논의 당시, 일반 근로자에게 적용되는 공휴일이 존재하지 않았다는 점을 감안할 때³⁷⁾, 「근로기준법」상 월 단위 휴식의 부여 필요성이 높았다는 점도 이러한 입법의 이유 중 하나였을 것이라고 생각된다.

한편 1953년 제정 「근로기준법」이 연·월차휴가의 금전보상을 인정한 이유는 명확하지 않다. 그러나 ① 출근율에 따라 부여되는 연차휴가의 보상적 성격을 반영하고 ② 1년에 취득할 수 있는 휴가일수(연차휴가 8일, 월차휴가 12일)까지만 실제 휴가일로 부여하도록 하여 과도한 휴가일 적치를 방지하기 위한 것이 아닌가라고 추측해 본다. 즉 1953년 제정 「근로기준법」상 휴가의 적치 및 소멸 시효에 관한 제한이 없었다는 점이 ‘연·월차휴가 금전보상’에 영향을 미쳤을 것이라 생각된다.

2. 주 40시간제 도입 이전의 연차휴가의 변천

39조 제1항)으로 요건이 변경되었다.

- 37) 「관공서의 공휴일에 관한 건」(대통령령 제124호, 1949. 6. 4. 제정)은 관공서의 공휴일을 ① 일요일, ② 1월 1일 -3일, ③ 식목일(4월 5일), ④ 추석(추수절), ⑤ 한글날(10월 9일), ⑥ 기독탄생일(12월 25일)로 정하고 있었는데, 이에 따라 공무원은 주휴일과 공휴일을 부여받음에도 불구하고, 일반 근로자들은 이들 기간에 쉬지 않는 것이 일반적이었다[한국사회사연구회, 『해방 후 한국의 사회변동』, 문학과 지성사, 1986, 47-49면]. 이러한 상황을 고려하면 「근로기준법」상 공휴일과 유사한 휴식을 부여하여 공무원과 일반 근로자의 형평성을 제고할 필요성이 있었으며, 이에 따라 월차휴가를 부여한 것은 아닌지 추측해 볼 수 있다.

1961년 개정 「근로기준법」에서는 ① 2년 이상 계속 근로한 근로자에게 계속 근로 1년에 대하여 연차휴가를 1일 가산하도록 하고(제48조 제2항), ② 휴가일수가 20일을 초과할 경우 초과일수에 대하여는 통상임금을 지급하고 휴가를 주지 않을 수 있도록 하였으며(제48조 제2항 단서), ③ 휴가 기간에 관한 임금을 취업규칙이나 기타로 정하는 바에 따라 통상임금 또는 평균임금으로 지급하도록 하였다(제48조 제3항). 이를 1953년 제정 「근로기준법」과 비교해 보면, 계속 근로에 따른 연차휴가의 가산이 도입되었다는 점이나 휴가의 상한을 연차휴가에 한정하였다는 점은 법정휴가일을 증가시킨 것이므로 연차휴가가 확대되었다고 평가할 수 있지만, 20일 초과분에 대한 금전보상 기준이 가산임금에서 통상임금으로 낮아지고 휴가일의 임금 기준도 평균임금에서 평균임금 또는 통상임금으로 변경되었다는 점은 휴가의 금전보상 수준이 저하되었다고 평가할 수 있다.

1980년 개정 「근로기준법」은 제48조 제5항에서 연차휴가권의 시효규정을 신설하여 연차휴가권의 행사기간을 1년으로 제한하였다. 1989년 개정 「근로기준법」은 휴가일수에 대한 변경으로 ‘1년 개근에 대하여 10일의 휴가, 9할 이상의 출근 때에는 8일의 휴가’로 확대하였다(제48조 제1항).

1996년 개정 「근로기준법」에서는 휴가일수가 20일을 초과할 경우 그 초과일수에 대하여는 통상임금을 지급하고 유급휴가를 주지 않을 수 있도록 한 제48조 제2항에 “30일을 초과할 경우에는 그 초과하는 일수에 대하여는 통상임금의 지급 없이 유급휴가를 주지 아니할 수 있다”라고 단서 조항을 추가하여, 휴가의 금전보상 상한선을 규정하였다. 또한 제48조의2로 사용자와 근로자대표와의 서면 합의에 따라 유급휴가일에 갈음하여 특정한 근로일에 근로자를 휴무시킬 수 있도록 하는 ‘유급휴가 대체’를 도입하였다.³⁸⁾

1997년 제정 「근로기준법」은 연차휴가에 관한 1996년 개정 「근로기준법」

38) 1996년 개정 「근로기준법」은 입법 과정에서 발생한 절차상의 하자로 인하여 그 유효성 논란이 제기되었다. 이에 노동계는 총파업을 실시하였고, 이 과정에서 1997년 「근로기준법 폐지법률」에 의하여 1996년 개정 「근로기준법」은 폐지되고, 이후 제정의 형식으로 개정된 1997년 제정 「근로기준법」이 시행되었다.

내용 중에서 ‘유급휴가 대체’(제48조의2)만을 계수하였고, 30일 초과 휴가 일수의 금전보상 제한은 수용하지 않았다.

3. 주 40시간제 도입 이후 연차휴가의 변천

2003년 개정 「근로기준법」에서는 주 40시간제 도입과 관련하여 휴가제도 전반에 관하여 많은 변화가 있었는데, 연차휴가와 직·간접적으로 연관이 있는 사항을 살펴보면, ① 월차휴가를 폐지하는 대신 근로 연수가 1년이 되지 않은 근로자에게는 폐지 전 월차휴가에 상당하는 휴가로서 1월 개근 시 1일의 유급휴가를 미리 사용할 수 있게 하고(제59조 제2항), ② 1년 동안 8할 이상 출근한 근로자에게 유급휴가를 15일 주고 3년 이상 계속 근로한 근로자에게는 15일의 연차휴가에 계속 근로 매 2년마다 1일을 가산하여 최대 25일까지 휴가를 주도록 하였으며(제59조 제3항 및 제4항), ③ 상한을 20일에서 25일로 늘이는 대신 한도를 초과하는 휴가 일수에 대한 금전보상(통상임금 지급)을 삭제함과 동시에 ④ ‘연차휴가 사용촉진제도’(제59조의2)를 도입하였다.

2003년 개정 「근로기준법」상 연차휴가제도의 변화는 “근로자의 삶의 질 향상과 기업의 경쟁력 강화에 이바지하기 위하여 법정근로시간을 단축하고 근로시간 및 휴가제도를 국제기준에 맞추어 개선하려는 것”이라고 하고 있지만, 국제기준을 감안한 휴가제도의 변경은 월차휴가의 폐지 등에 한정되고³⁹⁾, 연차휴가는 월차휴가의 폐지에 따른 합리적인 휴가일수의 조정에 의한 것이라고 보아야 한다.

2012년 개정 「근로기준법」은 연차휴가에 관하여 ① 제60조 제1항의 8할을 80%로, 제60조 제6항 제2호의 ‘보호휴가’를 ‘휴가’로 변경하고 ② 1

39) 2003년 개정 「근로기준법」【제·개정이유】중 주요골자(라)에서는 “국제적인 입법례에 따라 월차유급휴가를 폐지하고, 여성인 근로자에 대하여 월 1일의 유급생리휴가를 주도록 하던 것을 무급화하여 사용자의 부담을 경감하도록 함”이라고 하여, 국제적인 입법례가 미친 영향을 월차휴가 폐지에 한정하고 있는 것으로 보인다.

년간 80% 미만을 출근한 근로자에게도 1개월 개근 시 1일의 연차 유급휴가를 주도록 규정하는 한편(제60조 제2항) ③ 연차휴가 사용촉진 조치를 시행할 수 있는 시점을 1년간의 휴가청구권 행사기한 ‘3개월 전’에서 ‘6개월 전’으로 변경하였다(제61조 제1호).

4. 소결 : 「근로기준법」상 연차휴가의 연혁적 특징

연차휴가에 관한 입법적 변천 과정을 살펴보면, 연차휴가의 요건, 내용, 효과에 관하여 많은 변화가 있어 왔다. 이러한 과정에서 월 단위 휴식제도인 월차휴가와 연 단위 휴식제도인 연차휴가가 통합되는 기본 구조의 변화도 발생하였다.

근로시간법제의 큰 입법적 방향성이라고 한다면 ‘근로시간 단축’이라고 할 수 있다. 그리고 그 정도에 대해서는 관점에 따라 차이가 있겠지만, 적어도 장시간 근로가 만연화되어 있는 우리나라에서 ‘근로시간 단축’이라는 방향성 자체는 많은 이들이 공감하고 있을 것으로 생각된다. 근로시간 단축의 방식은 다양한 방식으로 전개될 수 있는데, 근로시간이 아닌 시간, 즉 휴식의 적극적 확보를 통하여 근로시간을 단축하는 입법적 방식이 ‘가장 인권적이고 효율적인 방식’으로 평가받고 있으며⁴⁰⁾, 실제로도 연차휴가가 연간 근로시간 단축에 미치는 영향도 큰 것으로 나타나고 있다.⁴¹⁾

하지만 「근로기준법」의 연혁적 변천 과정에 한정한다면, 휴일일수의 확대는 입법적 변천 과정에서 나타난 주요한 쟁점 사항이라고 보기 힘들다. 개근을 전제로, 근로자가 취득할 수 있는 휴가일은 1953년 제정 「근로기준법」상 20일(연·월차휴가)과 현재 15일부터 25일까지로 큰 차이가 없다. 결국 2003년 폐지된 월차휴가를 고려한다면, 휴가제도의 큰 틀은 주로 요건에서의 보상적 성격(취득 요건)와 관한 부분과 사용에서의 보상적 성격

⁴⁰⁾ Jeff Kenner, *EU and International Labour Law*, Hart Publishing, 2012 47면.

⁴¹⁾ 박제성 外(이철수 집필부분), 『장시간 노동과 노동시간 단축(Ⅱ)-장시간 노동과 노동법제』 한국노동연구원, 2012, 136-137면.

에 관한 부분(사용과 금전보상)에 집중되어 있다.

<표 3> 연차휴가제도의 도입과 변천

시기	요건/일수	요건 미달	가산 휴가	월차 휴가	취득 상한	금전보상
1953	1년간 개근 : 8일 9할 : 3일	휴가 미부여	없음	1월당 1일	20일	20일↑ 금전보상 가능 (선택적)
1961	상동	휴가 미부여	1년당 1일	상동	없음	상동
1980	상동	휴가 미부여	상동	상동	없음	상동
1989	1년간 개근 : 10일 9할 : 8일	휴가 미부여	상동	상동	없음	상동
2003	1년간 8할 : 15일	근속 특례*	2년당 1일	폐지	25일	상한초과, 사용촉진 통지시 보상의무 없음
2012	1년간 80% : 15일 (원칙)	요건 특례**	상동	-	25일	상동

* 근속특례는 1년 미만 근로자, 요건 특례는 80% 미만 출근자 : 1월당 1일

** 취득 상한이라 함은 1년간의 요건 충족을 통하여 취득할 수 있는 총 휴가일 상한을 말함.

V. 연차휴가의 구조에서 나타난 보상적 성격

1. 연차휴가의 기본적 취득요건의 보상적 성격

연차휴가 취득요건과 관련하여, 보편적인 휴식으로 정하고 있는 ILO 협

약(제132호) 등과 달리 「근로기준법」에서는 ‘1년간 80% 출근’ 내지 ‘1월 간 개근’ 등의 취득 요건을 규정하고 있다. 이 중 ‘1개월 개근’의 요건은 2003년 개정 「근로기준법」에서 월차휴가를 폐지하는 과정과 8할 미만 출근자의 비례적 휴가 부여를 위하여 도입된 것으로, 연차휴가를 완전하게 취득하는데 필요한 기간이 미달되는 근로자에게도 비례적으로 휴가권을 인정하고자 하는데 그 의의가 있다.⁴²⁾ 따라서 연차휴가의 원칙적인 취득 요건은 ‘1년 이상 계속 근로’와 ‘80%의 출근’이라고 할 수 있다(완전한 휴가취득).

연차휴가가 근로관계에 있어서 보편적으로 인정되어야 하는 권리라는 점을 고려한다면, 출근율을 기준으로 연차휴가를 부여하는 입법 태도가 바람직하다고 볼 수는 없다. 그러나 정당한 이유 없이 무단으로 결근하거나, 출근이 일정치 않는 등 출근 성적이 불량한 것은 근로계약 관계의 주된 의무인 근로제공 의무를 온전히 이행하지 않는 것으로 근로계약 당사자의 신뢰를 손상시키는 대표적인 행위기 때문에⁴³⁾, 이를 바탕으로 근로자의 권리 취득에 불이익을 주는 것이 반드시 금지되어야 하는 것은 아니다.⁴⁴⁾ 현행 「근로기준법」은 1년간 개근을 원칙으로 하는 등 엄격한 요건을 규정하고 있는 제정 「근로기준법」과 달리 것이 아닌, 80%라는 완화된 요건을 규정하고 있으므로, 기본적 취득요건 자체는 보편성을 갖는다고 평가할 수 있다.

다만 이러한 완화된 요건에도 불구하고, 연차휴가의 출근 요건은 소정근로일을 바탕으로 한 출근율에 따라 산정한다. 연차휴가 출근율 산정은 ‘근로자의 기여도’를 측정하기 위한 것이지만, ‘80%의 출근율’ 달성 여부는

42) ILO 제132호 협약 제4조 제1항에서는 “어느 해의 근무기간이 제3조에서 정하는 연차 유급휴가를 완전하게 받을 자격을 취득하는 데 필요한 기간에 미달되는 근로자는 당해 연도에는 당해 연도의 근무기간에 비례하는 유급휴가를 받을 권리를 가져야 한다”라고 규정하고 있다.

43) 하갑래, 앞의 책, 676면.

44) 菅野和夫, “年次有給休暇の法構造”, 「文獻研究勞働法學」, 勞働法文獻研究會編, 總合勞働研究所, 1988, 450면.

일반적인 출근 의무를 위반한 결근에 좌우되기보다는 휴업기간, 휴직기간, 쟁의행위기간, 노동조합 전임자의 전임기간, 징계기간 등을 어떻게 취급할 것인가가 문제된다. 이에 대하여 출근간주설, 소정근로일제외설, 결근설, 비례삭감설 등이 제시되고 있는데, 소정근로일을 어떻게 해석하는지 또는 대상 기간의 성격을 어떻게 파악하는지에 따라 결과를 달리 판단하고 있다. 이에 관하여 대법원 대법원 2011다4629 판결이 취한 방식은 비례적 삭감설로서⁴⁵⁾, 이는 근로의무의 불이행이라는 ‘결근’ 개념보다는 문제가 되는 대상기간을 소정근로일수에서 제외하여 출근 요건을 판단하는 구조를 취하고 있다.⁴⁶⁾ 또한 행정해석은 주휴일이나 연차휴가의 성질상 현실적으로 출근하지 않았지만 출근으로 간주되는 기간이 주·월·년의 산정기간 전체에 걸친 경우에는 이를 부여하지 않아도 된다고 보며⁴⁷⁾, 대법원은 ‘직위해제기간을 결근으로 간주하는 취업규칙의 효력’을 인정하는 등 엄격한 소정근로일의 해석을 통한 연차휴가 취득을 인정하고 있지 않다.⁴⁸⁾ 이러한

- 45) 비례삭감설은 해당 기간을 소정근로일수에서 제외하여 ‘80%의 출근’ 요건을 판단 하되, 구체적인 휴가일수는 연간 총 소정근로일수에 대한 나머지 소정근로일수의 비율을 곱하여 산정하는 방식을 말하는데, 행정해석(임금근로시간정책팀-3228, 2007.10.25.) 및 「공무원복무규정」 제17조 제2항의 휴직 기간에 대한 연가일수 산정식이 이 방식을 취하고 있다. 이 학설들을 구체적으로 적용해 보면, 휴일이 114일로 소정근로일이 251일이고, 쟁의행위 기간이 90일, 개인 사정으로 결근한 날이 7일인 경우, 근속연수를 고려하지 않았을 때의 각 입장에 따른 출근율 및 연차휴가일수는 다음과 같이 산정된다.

학 설	출근율	연차휴가일수
소정근로일제외설	$0.96 = (251 - 90 - 7) \div (251 - 90)$	15일
비례삭감설	$0.96 = (251 - 90 - 7) \div (251 - 90)$	약 9.5일 $= 15 \times \{ (251 - 90 - 7) \div 251 \}$
출근간주설	$0.97 = (251 - 7) \div 251$	15일

- 46) 이에 관한 논의는 김근주, 앞의 학위논문, 125-129면 참조.
- 47) 임금근로시간정책팀-3228, 2007.10.25.(예컨대 산전후휴가 기간이 특정한 달의 근로일 전체에 걸쳐 있는 경우에는 그 달의 월단위 연차휴가를 주지 않아도 되고, 연차휴가 사용기간이 특정 주의 근로일 전체에 걸친 경우에는 주휴일을 주지 않아도 된다고 본다. 이러한 행정해석의 입장은 주휴일이나 연차휴가 등을 계속적인 근로에 따른 피로 누적을 회복하기 위한 것으로 보고 있는 듯하다).
- 48) 대법원 2008.10.9. 선고 2008다41666판결.

방식은 연차휴가의 해석을 단지 근로관계에 기초한 휴가라고 보기보다는 실질적으로 일을 했는지 여부, 즉 사용자에게 기여했는지 여부를 더 중시하는 것으로, 이는 ‘근로보상적 성격’이라고 하기에는 무리가 있다.⁴⁹⁾

2. 가산휴가 규정의 보상적 성격

가산휴가는 1961년 개정 「근로기준법」 제48조 제2항에서 ‘계속 근로 1년마다 1일의 휴가’를 가산한 것을 시초로, 2003년 개정 「근로기준법」에서 현재와 같이 25일을 한도로 최초 1년을 초과하는 매2년에 대하여 1일씩 휴가를 가산하도록 규정되었다. 이와 같은 가산휴가제도는 연차휴가의 보상적 성격에 기인하는 것으로, 근로자 기여도 판단이 출근율에 한정되지 않고 계속 근로에 따른 기업에 대한 공로도 연차휴가 부여에 영향을 미친다는 점을 확실히 했다는데 그 의의가 있다(공로보상적 성격). 가산휴가는 기본 요건인 출근율을 충족하는 경우 휴가의 가산에 관한 문제이므로, 취득요건은 아니다(부차적 성격).

계속 근로기간에 대한 우대는 주로 약정 근로조건에서 문제가 되며, 이에 대한 우대를 법정 근로조건으로 규정하는 경우는 드물다.⁵⁰⁾ 다만 우리나라와 일본과 같이 ‘연공서열제(年功序列制)’에 따라 임금과 근로조건을 규율해 왔던 체제에서는 법정 근로조건으로 계속 근로기간에 대한 우대를 규정하는 경우가 있는데, 가산휴가 역시 연공서열제를 감안하여 규정된 것이라고 생각된다.⁵¹⁾ 그렇지만 「근로기준법」상 계속 근로에 대한 우대 규정

49) 오히려 이러한 측면을 보면 연차휴가는 ‘종속보상적 휴가’라고 하는 것이 그 본질을 잘 나타내는 것은 아닌가 하는 생각이 든다.

50) 濱口桂一郎, 「労働法政策」, ミネルヴァ書房, 2004, 37면에서는 비교법적으로 볼 때, 법정 근로조건 중에서는 해고예고 기간 정도가 신뢰 이익을 바탕으로 하여 계속 근로기간을 우대하는 예외적인 형태라고 설명하고 있다.

51) ILO 제47호 「연차 유급휴가 권고」(1936)에서는 제3조에서 계속 근로기간의 증가에 따라 휴일을 더 부여하도록 노력할 의무를 규정하였지만, 이후 연차휴가에 관한 ILO 협약 및 권고에서는 이와 유사한 내용을 포함하지 않았다.

은 가산휴가가 유일하기 때문에 계속 근로에 대한 차별적 처우를 법정 근로조건으로 규정하고 있는 가산휴가가 「근로기준법」상 정당화될 수 있는지가 문제되는데, 특히 「헌법」 제11조 제1항에 근거한 「근로기준법」상 총칙 규정 중 제6조(균등한 처우)의 취지와 가산휴가의 취지가 배치되는 것이 아닌지 문제될 수 있다.⁵²⁾

현행 「근로기준법」에서 가산휴가일은 2년당 1일이며, 근속 20년까지 총 10일(총 한도 25일)한도로 인정된다. 이러한 한도가 도입된 2003년 개정 「근로기준법」이전을 살펴보면, 가산휴가 규정은 1년당 1일이며, 휴가의 총 한도도 20일까지로 존재하였다. 하지만 근로자가 휴가 한도를 넘어서 취득하는 경우에는 사용자가 휴가와 금전보상을 선택할 수 있도록 하였다. 반면 현행 「근로기준법」상 가산휴가일은 20년 근속(가산휴가 10일)까지의 가산휴가만을 인정하고 그에 대한 금전보상도 허용하고 있지 않다. 이처럼 최근 연차휴가에 관한 규율은, 적어도 직접적으로 의도한 바는 아니었다고 생각하지만, 이전 규정들과 비교할 때 계속 근로기간 전체가 아닌 업무 능력이 좋은 시점까지만을 보상하는 것 같은 형태를 취하고 있다.⁵³⁾

3. 연차휴가 취득요건의 특례 : 월단위 연차휴가

52) 다만 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조와 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제2조에서 차별적 처우의 정의에 대해 ‘임금 그 밖의 근로조건 등에 있어서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것’이라고 규정하고 있으므로, 계속 근로에 따른 연차휴가의 차등적 부여는 적어도 현행 「근로기준법」이라는 법적 근거에 따른 것으로 합리적인 이유가 있는 것으로 보아 차별적 처우에 해당하지 않는다고 본다.

53) 이러한 구조의 보상 시스템은 ‘임금피크제’와 유사하게 보인다. 비록 가산휴가가 임금과 같이 일정한 시점을 기점으로 줄어드는 것은 아니지만, 생산성이 가장 좋은 일정 시점까지만을 우대하고 있기 때문이다. 예를 들어 통상적인 기업에 25세부터 35세까지 입사한다고 할 때, 20년 근속(가산휴가 10일)하는 시점은 45세부터 55세까지로 임금피크제 적용 시점과 유사하며, 통상적으로 이 시점은 업무능력 또는 생산성이 극대화되는 시점과 일치한다. 이러한 관점에서 보면, 가산휴가의 보상적 성격의 본질이 기업의 계속 근로기간 전체를 대상으로 하고 있지 않기 때문에 ‘공로보상적 성격’이라고 하는 것은 적절한지 의문이다.

(1) 월 단위 연차휴가의 법적 근거

「근로기준법」상 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만 근로 또는 80% 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있다(제60조 제2항). 「근로기준법」상 완전한 휴가(15일+a)를 취득하기 위해서는 ‘계속 근로기간이 1년 이상인 근로자가 80% 이상 출근한 경우’이어야 하지만, 취득 요건에 미달하는 근로자라 하더라도 연차휴가를 전적으로 배제하는 것은 보편적 근로조건이라는 연차휴가의 근로권적 성격에 반하므로⁵⁴⁾, 「근로기준법」은 이러한 특례를 규정하여 예외를 인정하고 있다.

그런데 이러한 월 단위 연차휴가는 완전한 휴가(15일+a)와 비교할 때 더 높은 근로자의 기여도인 ‘개근’을 그 요건으로 하고 있다. 월 단위 연차휴가에서 더 엄격한 취득 요건을 적용하는 이론적 근거는 명확하지 않다. 다만 연차휴가의 보상적 성격을 근거로 판단해 보면, 월 단위 연차휴가는 원칙적으로 연차휴가 대상이 아님에도 불구하고 ‘근로자의 기여도’가 현저하게 높은 ‘개근’과 같은 경우에 한하여 예외적으로 휴가를 부여한다는, 일종의 시혜적 휴가로 파악한 듯하다. 즉 「근로기준법」은 연차휴가의 보편적 근로조건성을 고려하여 월 단위 연차휴가를 규정하면서도, 이를 예외적인 것으로 보고 엄격한 요건에 의하여 판단하는 구조를 취하고 있는 것이다.

(2) 월 단위 연차휴가의 휴식성⁵⁵⁾

「근로기준법」 제60조 제3항에서는 “사용자는 근로자의 최초 1년간의 근로에 대하여 유급휴가를 주는 경우에는 제2항(1개월 개근시 1일의 유급휴가)에 따른 휴가를 포함하여 15일로 하고, 근로자가 제2항에 따른 휴가를 이미 사용한 경우에는 그 사용한 휴가 일수를 15일에서 뺀다”라고 규정하

⁵⁴⁾ 헌법재판소 2002. 11. 28. 선고 2001헌바50 참조

⁵⁵⁾ 이하의 내용은 김근주, 앞의 글, 9면 이하의 내용을 수정·보완한 것이다.

여 월 단위 취득 연차휴가를 향후 연차휴가의 발생일수와 연계시키고 있다.⁵⁶⁾

월 단위 연차휴가는 1년 미만의 근로자에 대하여 비례적으로 연차휴가를 부여한다는 데 그 의의가 있지만⁵⁷⁾, 계속 근로기간이 1년 미만인 경우와 1년 이상인 경우의 연차휴가 부여 기준이 다르기 때문에, 동일한 기간의 출근이 출근을 산정에서 중복되어 평가되지 않기 위하여 「근로기준법」은 양자 사이의 조정 규정(제60조 제3항)을 두고 있다. 그런데 구체적인 산정에 있어서 기간제 근로자와 같이 계속 근로기간이 한정되어 있는 경우에는 실제 휴가일로 부여받을 수 있는 휴가일수가 제한된다는 문제점이 있다.

<표 4> 기간제 근로자의 연차휴가 발생일수

2013.1.1.	2013.12.31.	2014.12.31
A	B	C
총 12일 중 11일 사용 可	(15-A) 4~15일	연차휴가 미사용수당 발생(15일)
고용 개시	계속 근로 1년 (계약 연장)	고용 종료
월 단위 연차휴가		완전한 연차휴가

예컨대 1년 계약을 체결한 기간제 근로자가 계약을 1년 연장했을 때, 근로기간 동안 전부 개근을 한 경우 B기간에 취득할 수 있는 휴가는 4일-15일로 구체적인 휴가일은 A기간의 휴가 사용에 영향을 받는다. 그리고 2014년 12월 31일이 되면 B기간의 출근율을 바탕으로 한 연차휴가가 발

⁵⁶⁾ 1년간 80% 미만 출근자에 대한 월 단위 연차휴가는 「근로기준법」 제60조 제3항의 적용 대상이 아니다.

⁵⁷⁾ ILO 제132호 협약에서는 취득 요건인 ‘최저 근무기간’을 6개월 미만으로 설정하도록 하는 한편, 1년간 근무에 대하여 최저 3근로주의 유급휴가를 부여하도록 함과 동시에(제3조 제3항), 1년 미만의 근무에 대해서는 근무기간에 비례하여 휴가를 부여하도록 하고 있다(제4조 제1항).

생하지만, 고용이 종료됨에 따라 휴가로 수령할 수 없고, 이를 연차휴가 미사용수당으로 수령할 수밖에 없게 된다.

한편 기간제 근로자가 계속 근로기간이 1년 이상인 경우 2년을 채우지 못하고 중도퇴직하는 경우, 중도퇴직 전 1년 미만의 근로는 월 단위 연차휴가가 부여되지 않는다. 즉 위의 표에서 근로자가 B 기간 중에 퇴직하는 경우에는 A 기간에 발생한 연차휴가만을 부여받으며, B 기간에 대해서는 적정한 휴식 보상을 받을 수 없게 된다. 이에 대하여 헌법재판소는 “... 근로연도 중도퇴직자는 중도 퇴직한 근로연도에도 직전 근로연도의 근로에 따른 연차유급휴가를 보장받을 수 있으므로 이로써 충분히 휴양의 기회를 가질 수 있고, 별도로 이 사건 법률조항이 정한 근로기간 1개월을 휴가일 수 산정단위로 하는 형태의 휴가를 보장받을 필요성이 적다 ...”라고 하면서, “... 이처럼 연차유급휴가는 근로자에게 1년 단위로 일정 기간의 정신적·육체적 휴양의 기회를 부여하려는 것이고, 근로기준법 제60조 제1항이 그 판단기준으로 근로연도 1년간의 재직 요건을 정한 이상, 이 요건을 충족하지 못한 근로연도 중도퇴직자의 중도퇴직 전 근로에 관하여 반드시 그 근로에 상응하거나 그 근로를 빠짐없이 반영하는 내용의 유급휴가를 보장하여야 하는 것은 아니다 ...”라고 판단하고 있다.⁵⁸⁾ 이에 따르면 기간제 근로자가 2년의 계약 기간을 채우지 못하는 경우에는 결국 월 단위 연차휴가만을 부여받을 수 있으며, 연차휴가 미사용수당도 발생하지 못할 수 있다. 예컨대 위의 사례에서 2013년 1월 1일부터 2014년 12월 1일까지 근로한 기간제 근로자의 경우 총 12일만의 휴가만이 발생하며 이를 1년 11개월동안 휴식으로 활용해야 한다는 결론에 이르게 된다.⁵⁹⁾

58) 2015. 5. 28. 2013헌마619 결정.

59) 위 사건에서 헌법재판소는 재판관 5대4의 의견으로 합헌결정을 내렸는데, 소수 의견(이정미·김창중·안창호·서기석 재판관 4인)에서는 “... (현행규정에 따르면) 11개월동안 개근한 뒤 퇴직하고 다시 취직해 11개월을 개근하면 (1개월당 하루씩) 22일의 휴가를 받을 수 있지만 1년 10개월을 한 곳에서 일하다가 퇴직하면 1년에 대한 연차휴가 15일만 받을 수 있다 ...”면서 “... 두 경우에 있어서 근로자의 휴양의 필요성에 차이점이 있다고 볼 수 없다 ...”고 보았다. 이 외에도 중도퇴직자에 대한 휴가 부여가 실무상 어려운 것이 아니라는 점, 휴가 부여가 사용자에게

결국 월 단위 연차휴가의 문제점의 근본적인 원인은 고용 형태에 따라서 실질적인 휴식을 위한 연차휴가로 작용하지 못한다는 점이다. 이러한 점을 고려하면, 연차휴가는 정규직으로서 1년 미만의 근로자에 대한 일시적인 불이익이 발생하는 점에 추가하여 기간제·파견근로자 등이 실질적인 휴식으로 활용할 수 없도록 하는 구조적인 문제점을 낳고 있다. 결국 연차휴가 취득요건의 특례인 월단위 연차휴가 부여에서는 연차휴가의 ‘고용형태 보상적 성격’, 즉 정규직만을 휴식으로서 연차휴가의 우선적 대상으로 설정하였다는 점을 잘 나타내고 있다.⁶⁰⁾

VI. 글을 마치며

이상으로 휴가제도의 구조, 연차휴가제도의 연혁적 변천, 그리고 현행 연차휴가제도의 분석을 통하여 연차휴가의 보상적 성격에 관하여 살펴보았다.

보상적 성격은 그 자체로도 연차휴가가 “보편적인 휴식”으로 작용하는데 있어서 부합되지 않는데, 더 나아가 현행 「근로기준법」은 그 보상의 목적과 방식에 있어서도 문제점이 나타나고 있다. ILO 국제기준이나 다른 국가들의 입법례와 달리 연차휴가가 보상적인 성격으로 규정되어 있다는 점은 그 자체로도 비판의 여지가 있기 때문에, 이러한 성격을 유지하기 위해서는 그 목적과 형식, 그리고 내용이 타당해야 한다는 점은 당연하다.

하지만 연차휴가는 근로보상적 성격을 바탕으로 하여 공로보상적 성격

큰 경제적 부담으로 작용하지 않는다는 점 등을 고려하여 위헌 의견을 제시하였다.

60) 이처럼 기간제·파견근로자 이외에도 연차휴가의 부여에 있어서 단시간근로자에 대한 불이익도 문제가 되는데, 이는 연차휴가제도의 문제라기보다는 단시간근로자에 관한 문제로 여기에서 다루지 않도록 한다. 이에 관해서는 이승욱, “단시간근로 규제 문제점과 과제”, 「서울대학교 법학」 제53권 제1호, 2012, 157-161면 참조.

이 더해진 휴가라기보다는 사실상 근로관계에 바탕을 한 근로보상적 성격 대신 사용자에게 종속성에 대한 보상의 성격이 짙으며, 실제 휴식 부여에 대해서 기간제근로자 등에 있어서 차별적인 형태로 이루어질 수밖에 없는 구조로 이루어져 있다. 결국 보편적 휴식으로서의 연차휴가의 보장적 성격의 필요성과는 별도로, 연차휴가에서 보상하고자 하는 바가 적정한지, 법적으로 수용가능한 것인지, 보상의 공평성과 타당성을 갖추고 있는지에 관하여 면밀하게 검토될 필요가 있다.

한편 최근 연차휴가에 대한 입법적 개정을 살펴보면, 대체휴일제도나 사용촉진제도 등 연차휴가의 사용과 보상에 관해서는 보상적 성격이 크게 완화되고 있는 경향이 나타나고 있다. 휴가는 ‘금전으로 환가할 수 없는 권리’라는 점에는 기본적으로 찬동하지만, 지난 1년간 사용자로부터 종속되어 있으면서 차곡차곡 적립해 온 연차휴가를 본인의 의지와 상관없이 일괄적으로 사용해야 하는 기간제 근로자와 같은 시간빈곤층(Time Poor)의 입장을 생각해 보면, 취득에 있어서 보상적 성격이 완화되지 않는 현실점에서 이러한 입법 방향이 타당한지에 관하여 고민해 보게 된다. 근로자의 선택에 따라 장기휴식을 부여받아 여가 생활을 향유하는 것이 연차휴가의 입법적 지향점이긴 하지만, 오히려 「근로기준법」과 같이 연차휴가 취득에 있어서 보상적 성격이 폐지되지 않는 현실을 고려한다면, 근로자의 의사에 기한 연차휴가 사용을 보장하고 남은 휴가일수를 금전으로 보상하는 것이 보다 체계적인 입법 구조가 아닐까 하는 다소 회의적인 생각을 지을 수 없다.

(논문발표 2015.7.18. 논문접수 2015.9.3. 심사의뢰 2015.9.4. 게재확정 2015.9.22.)

참고 문헌

- 권영성, 『헌법학원론』, 2011 법문사
 김영선, 『잃어버린 10일-경영 담론으로 본 한국의 휴가 정치』, 이학사, 2011.
 김근주, 『연차휴가제도에 관한 연구』, 한양대학교 박사학위논문, 2012.

- 김근주, “연차휴가의 입법적 개선 방안”, 『노동법학』 제50호, 한국노동법학회, 2014.
- 노동법실무연구회(김홍준 집필부분), 『근로기준법주해 I』, 박영사, 2010.
- 노호창, “쟁의행위와 연차 유급휴가”, 『월간 노동리뷰』 중 노동판례리뷰, 한국노동연구원, 2014.03.
- 박제성·강성태·김홍영·도재형·박귀천·이철수·최석환·배규식, 『장시간 노동과 노동시간 단축(II)-장시간 노동과 노동법제』, 한국노동연구원, 2012.
- 박종희, “연차휴가일수 비례산정의 타당성”, 『월간노동법률』, (주)중앙경제, 2014.03.
- 신인령, 『여성·노동·법』, 풀빛, 1985.
- 이승욱, “단시간근로 규제의 문제점과 과제”, 『서울대학교 법학』 제53권 제1호, 서울대학교 법학연구소, 2012.
- 이흥재, “근로기준법 제정심의의 주요쟁점”, 『서울대학교 법학』 제50권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2009.
- 이흥재, 『노동법 제정과 전진한의 역할-국회속기록의 현장증언-』, 서울대학교출판문화원, 2010.
- 장지연, “출산 및 양육과 관련된 휴가제도의 국제비교”, 『국제노동브리프』, 한국노동연구원, 2005.03.
- 하갑래, 『근로기준법(제26판)』, (주)중앙경제, 2015.
- 한국사회사연구회, 『해방 후 한국의 사회변동』, 문학과지성사, 1986.
- 菅野和夫, “年次有給休暇の法構造”, 『文獻研究労働法學』労働法文獻研究會編, 総合労働研究所, 1988.
- 濱口桂一郎, 『労働法政策』, ミネルヴァ書房, 2004.
- Alan, B. *Paid Annual Leave and the Long Term Sick: Third Time Lucky for the United Kingdom*, Industrial Law Journal 36(3), 2007.
- European Industrial Relations Observatory, *Guidance on the implementation of the European Working Time Directive*, 2005.
- Jeff, K. *EU and International Labour Law*, Hart Publishing, 2012.

<Abstract>

The Critical Review on Compensative Characteristic of Annual Holidays

Keunju Kim^{*}

Annual Holidays is paid time off granted by employers for rest of employees. Most countries around the world have the provisions in Labour Law to mandate that employers give a certain number of paid leaves per year to employees regardless of employment status. On the contrary, in Korea the Employment Standards Act(ESA) section 60 provides requirement for acquisition on annual holidays based on absence ratio in employment. This legislative form is different from international labour standard and EU directive as well as other countries. In this difference, we can find that annual holidays system in Korea have unique characteristic, so called “Compensative Characteristic of Annual Holidays”

In this article, I try to resolve a few questions relating to the characteristic, why it is built, what it is aiming at, whether it is valid in the legal system to regulate employment relations, and so on. The first method for this purpose is to systematise the rest periods system in ESA and to confirm the compensative characteristic of similar concepts such as weekly rest. The next step is reviewing the history of related articles in ESA and finding the legislative trends about it. The Last and the most important thing is to make an interpretation relating to

^{*} Lecturer, Hanyang University.

provisions of annual holidays, “once an employee worked for 80% of total working days of the first year, he is entitled to use 15 days’ annual leave during the next one year” and “Even if an employee has not completed his first year, he can use annual leave. In that case, he can use 1 day of leave if he had worked one full month.” These are intended to compensate for employment itself in a literal sense, but these are discriminating against non-standard workers or employees who exercise employment rights such as industrial action or leave of absence for maternity(or medical) reasons.

Key Words: Annual leave, Annual holidays, Rest periods,
Discriminations against non-Standard Workers,
Weekly rest